



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento avente il n. 43808 del registro generale affari contenziosi, anno 2018

TRA

Parte_1 (CF: **C.F._1**) elettivamente domiciliata in Roma, Via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Baudino che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

DOTT. **CP_1** (CF: **C.F._2**)

CONVENUTO CONTUMACE

E

Controparte_2 (P.IVA e CF **P.IVA_1**) con sede in Roma Via Antonio Bertoloni n. 44, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Misurina n. 80 presso lo studio dell'Avv. Maria Ester Balduini che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: responsabilità professionale medica

Conclusioni per parte attrice: *"Voglia l'Ill.mo tribunale adito per tutti i motivi sovraesposti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione in via preliminare riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti nella causazione del danno subito dalla Signora **Parte_1** a seguito dell'evento sopra descritto; per l'effetto, condannare i convenuti in solido, in favore dell'attrice, al risarcimento di tutti i danni patiti come sinora quantificati nei paragrafi 13 e 14 della narrativa del presente atto, salvo la diversa somma che risulterà quantificata in corso di causa anche a seguito della valutazione, eventualmente in via equitativa, del Giudice nonché alla rifusione delle*

spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come da legge, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si chiede, in caso di contestazione relativa al quantum debeatur, volersi disporre CTU medica per l'accertamento della natura e delle cause della patologia da cui è afflitta l'attrice, nonché nella misura e dell'incidenza della invalidità permanente prodottasi".

per parte convenuta *Controparte_2* “ *Voglia l'On.le Tribunale adito -rigettare la domanda dell'attrice perché infondata in fatto ed in diritto; in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre le pretese risarcitorie della Signora *Pt_1* nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti, limitando e graduando la misura della responsabilità di *Controparte_2* [...] rispetto a quella diversa responsabilità che dovesse risultare imputabile al Dott. *CP_1* ; quindi accertare e dichiarare che la responsabilità del fatto dannoso è ascrivibile in via esclusiva al Dott. *CP_1* ; quindi accertare e dichiarare che la responsabilità del fatto dannoso è ascrivibile in via esclusiva al Dott. *CP_1* ,e condannare il sanitario al pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore dell'attrice, manlevando *Controparte_3* da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio".*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio il dott. *CP_1* e la *Controparte_2* al fine di vedere accertata la loro responsabilità per aver agito con imperizia, imprudenza e negligenza nell'esercizio della professione medico-chirurgica relativa all'intervento di chirurgia estetica del 27.08.2016.

A sostegno della domanda parte attrice assumeva:

- che, al fine esclusivo di migliorare il proprio aspetto fisico, e, quindi, con finalità essenzialmente estetiche, si rivolgeva al dott. *CP_1* , medico specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, per ottenere un aumento di volume del proprio seno;
- che, pertanto, si rivolgeva direttamente al dott. *CP_1* che la rassicurava sulla semplicità dell'intervento chirurgico del caso, sui risultati immediatamente visibili e sulla brevità della convalescenza;
- che, dopo aver preso atto delle condizioni cliniche della paziente, il dott. *CP_1* , in data 21.07.2016, stilava il seguente piano terapeutico: “ *Preventivo €2.990 tutto incluso con protesi rotonde Allergan sede *Controparte_4* dimmisione+2 ore recupero 24 ore...Mastoplastica Gold Standard*” ;
- che in data 25.07.2016, sempre su indicazione del dott. *CP_1* , seguiva la stesura di un piano di accertamenti da effettuare in vista dell'intervento, presso il Centro BIOS di Roma tra cui: Rx Torace, ECG, prelievi ematici ed esame delle urine;

-che il dott. CP_1 informava la Pt_1 di aver prenotato l'operazione per il giorno 27 agosto 2016 e che, vista la negatività degli esami strumentali preoperatori, in tale data, alle ore 12.30 in regime di Day Hospital l'avrebbe sottoposta ad intervento così descritto: *“Impianto di protesi mammaria retromuscolare 410 FM 310>12. Emostasi”*;

- che, al termine dell'intervento, non risultando immediate complicanze, dopo aver provveduto a corrispondere al professionista l'importo di euro 3.600,00 a saldo dell'intero ammontare pattuito, veniva dimessa senza drenaggi e/o fasciature contenitive, con l'indicazione di riprendere la vita sociale e professionale di prima, con l'esclusiva prescrizione di eseguire esercizi di mobilizzazione degli arti superiori più volte al giorno;

-che, sottoponendosi a controlli di routine, sempre presso il dott. CP_1, rilevava un'ampiezza eccessiva del solco intrammario, un antiestetico avvallamento al centro delle due mammelle nonché il posizionamento troppo superficiale delle protesi, facilmente palpabili, che rendevano l'aspetto del seno del tutto innaturale;

-che, preso atto delle carenze dell'intervento chirurgico eseguito dal predetto professionista, si sottoponeva ad una visita presso il dott. Persona_1, medico legale, il quale, sulla base della documentazione sanitaria e dell'esecuzione di altri esami strumentali, tra cui una RMN delle mammelle, stilava un primo parere circa l'inadeguatezza del trattamento;

-che, pertanto, la Pt_1 in data 18.04.2017, diffidava legalmente sia il dott. CP_1 che la CP_2 [...] chiedendo il risarcimento dei danni subiti anche a mezzo della Compagnia Assicurativa di riferimento, ma la richiesta restava senza esito;

-che, nel tentativo di risolvere in via bonaria la questione, veniva esperita la procedura di mediazione che si concludeva negativamente a causa della mancata partecipazione dei convenuti;

-che, in data 09.11.2017, il dott. Per_1 completava la relazione medico legale sulla persona dell'attrice, così evidenziando: *“Esiti disestetici di pregresso intervento di mastoplastica additiva con evidente asimmetria mammaria alla contrazione dei muscoli pettorali associata allo sviluppo di solco orizzontale sotto-areolare in corrispondenza del punto di passaggio tra tessuto autologo ed impianto protesico..”*;

-che tale quadro clinico, definito in letteratura *“double bubble”* era verosimilmente riconducibile ad una inadeguata preparazione chirurgica del muscolo pettorale che, non adeguatamente sezionato, diventa un corpo unico con la protesi che finisce per seguirne i movimenti, anziché cadere in basso per andare ad integrarsi con il corpo ghiandolare della mammella, producendo una *“dismorfia dinamica; in virtù della totale assenza, nel caso di specie, di eventuali fattori costituzionali anche concausali nel determinismo del quadro, si ritiene con ragionevole certezza che gli esiti disestetici*

rilevati siano inequivocabilmente riconducibili all'operato del Chirurgo operatore, la cui condotta risulterebbe quindi censurabile per imperizia”;

-che il Consulente, non solo censurava la procedura chirurgica eseguita, ma, altresì, la gestione della paziente nel post operatorio, sia per quanto attiene all'indicazione di riprendere immediatamente l'attività lavorativa (svolgendo ella il ruolo di Assistente di volo e, come tale, sottoposta a ripetuti cambi di pressione in cabina), in assenza di fasciature contenitive ,con la inopportuna prescrizione di esercizi di mobilitazione degli arti superiori a partire dalla stessa giornata dell'intervento; sia per l'assenza di certificazioni rilasciate dal dott. CP_1 relative ai controlli eseguiti in regime ambulatoriale e della errata prescrizione di un farmaco antistaminico (Accoleit 20 mg), da prendere ogni giorno per 4 mesi, preparato che, tra l'altro, era stato ritirato dal commercio in data 22.12.2016; -che, a tutt'oggi, le condizioni estetiche dell'attrice sono rimaste immutate e, pertanto, è suo diritto ottenere la restituzione dell'importo di Euro 3.600,00 già corrisposto per la prestazione al dott. CP_1 , oltre il danno, come quantificato nella relazione medico legale dal dott. Per_1 ossia: inabilità temporanea assoluta giorni 20;

-inabilità temporanea parziale al 50% giorni 40%;

- danno biologico 5%, con riconoscimento del danno morale, per un totale di euro 9.790,22.

Chiedeva, pertanto, il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della condotta sanitaria imperita e negligente del dott. CP_1 con la condanna del professionista, in solido con la struttura convenuta.

Si costituiva la CP_5 Controparte_2 contestando la propria legittimazione passiva, atteso che la Pt_1 si era rivolta direttamente al dott. CP_1 , professionista non legato da alcun rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato con la Casa di Cura, ed in ogni caso non ravvisandosi nell'atto introduttivo contestazioni, anche generiche, alle prestazioni direttamente rese dalla CP_2 alla paziente, con conseguente completa estraneità della Struttura ai fatti ed alle doglianze lamentate dall'attrice. In ogni caso, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del dott. CP_1 , ne chiedeva la condanna in regresso ex art. 2055, comma 2, c.c.

La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione hic et inde prodotta e l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio con la nomina dei Dott.ri Persona_2 e Persona_3 .

In data 14 maggio 2024 questo Giudice, subentrato medio tempore nel ruolo, tratteneva la causa in decisione con termini alle parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Risulta documentalmente provato che *Parte_1* in data 27.18.2016 si è sottoposta presso la *Controparte_2* di Roma, ad intervento chirurgico di mastoplastica additiva ad opera del dott. *CP_1* che ha agito nella qualità di libero professionista.

La fattispecie in esame ha ad oggetto un intervento di chirurgia estetica, essendosi la *Pt_1* rivolta al chirurgo plastico per migliorare un disagio fisico consistente in una ipotrofia del seno (e, dunque, per raggiungere un determinato risultato), e non per fini curativi, anche se è pacifico che l'obbligazione del medico è comunque un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Ciò premesso, occorre qualificare il tipo di responsabilità ascrivibile al sanitario convenuto, atteso che l'evento risale a periodo antecedente alla entrata in vigore della legge n. 24/2017 *Parte_2*. Dalla giurisprudenza consolidata prima dell'entrata in vigore delle leggi c.d. Balduzzi e *Pt_2* era stato sancito il principio secondo cui sia il rapporto del paziente con la struttura sanitaria sia quello con il medico curante, si inquadra nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù della stipulazione, da un lato, di un contratto atipico, definito di ospitalità o di assistenza sanitaria, dall'altro, della sussistenza di un contatto sociale qualificato.

L'art. 3 del d.l. 158/2012 ha, in primo luogo, escluso la responsabilità penale del medico che si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e che si ritrovi in astratto in ipotesi di colpa lieve, mantenendo fermo comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. Orbene, il richiamo all'art. 2043 c.c. nella citata legge, ha creato dei contrasti giurisprudenziali circa l'applicazione dei tipici criteri di accertamento della responsabilità civile del medico improntati, in via consolidata, sul contatto sociale e sullo schema contrattuale. La Suprema Corte è intervenuta per chiarire che anche dopo la legge Balduzzi, la materia della responsabilità civile restava ancorata all'interpretazione consolidata sulla natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria da contatto sociale.

Successivamente, la Corte di Cassazione, prendendo atto delle novità normative *medio tempore* intervenute, ha dovuto precisare che l'applicazione al medico dello statuto della responsabilità aquiliana è oggi sancita in modo esplicito dalle disposizioni contenute nella Legge Gelli che ha innovato la disciplina relativa alla natura della responsabilità del personale sanitario, il quale, nel nuovo sistema, risponde, appunto, a titolo extracontrattuale; ha ribadito, invece, che non vi sono state modifiche in ordine alla natura della responsabilità della struttura sanitaria, che resta di tipo contrattuale come ritenuto dalla giurisprudenza precedente.

L'art. 7, comma 3, della citata legge, infatti, qualifica quella del medico in termini di responsabilità extracontrattuale, prevedendo espressamente che *“l'esercente della professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”*.

Con la sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019, la Suprema Corte ha segnatamente affrontato la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017. Ed in effetti, in merito alla collocazione intertemporale della nuova disciplina, ha affermato il principio di diritto secondo cui *le norme sostanziali contenute nella Legge n. 189/2012, al pari di quelle contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.*

Ciò posto, la struttura convenuta, sarà contrattualmente responsabile nei confronti del paziente per l'indampimento della prestazione medica svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario, pur in difetto di un rapporto organico di lavoro subordinato (come nel caso di specie).

A tale stregua, valutando la posizione del dott. CP_1, escluse le ipotesi di applicabilità dell'art. 2043 c.c. in relazione alla legge Balduzzi e di retroattività della legge Gelli-Bianco, egli è tenuto a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, atteso che il fatto contestatogli risale al mese di dicembre 2016, epoca in cui la Legge Gelli legge non era ancora in vigore.

Riguardo all'onere probatorio, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "*leges artis*" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione" (Cass. sez. 3 n. 28991 del 11/11/2019; Cass.sez. VI - 3, n. 18102 del 31/08/2020). Il principio sopracitato, sancito dalla Corte di Legittimità, è chiaro nel disporre che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore sanitario dimostrare che tale inadempimento non vi è stato.

Per quanto attiene al nesso causale, in tema di responsabilità civile, è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano

- ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Di conseguenza è censurabile la condotta del medico ritenuta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.. ove il danneggiato, provato il contratto o il contatto sociale intercorso con il convenuto, dimostri i profili rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle *leges artis* e dai canoni di diligenza (prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività) e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. Civ. sez. III, 12.09.2013 n. 20904). Pertanto, il sanitario, essendo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n. 16123/2010; cfr anche Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009).

Definita giuridicamente la fattispecie in esame, deve rilevarsi come nel corso del presente giudizio è stata svolta ctu medico legale nella quale i consulenti hanno preliminarmente descritto le possibili tecniche di mastopastica additiva, con specifico riferimento alla collocazione delle protesi mammarie e hanno spiegato che dette protesi possono essere posizionate in sede sottomuscolare totale (posteriormente al muscolo grande e piccolo pettorale), in sede retromuscolare (posteriormente al solo muscolo grande pettorale: tecnica dual plan) ed in sede retromammaria (posteriormente alla ghiandola mammaria e anteriormente al muscolo grande pettorale). Tanto premesso, hanno evidenziato come il criterio da utilizzarsi per la scelta del piano di alloggiamento protesico è determinata dalle peculiari caratteristiche della paziente (corporatura, volume e forma del seno). Nel caso della *Pt_1* hanno chiarito, è stato eseguito un posizionamento retromuscolare che, seppur consonso alla sua struttura fisica, tuttavia, non risulta essere esente da rischi post-operatori in quanto non consente al chirurgo di avere un pieno controllo sulla forma definitiva del seno, con particolare riferimento alla posizione del solco sottomammario e allo spostamento della protesi mammaria durante la contrazione del muscolo pettorale. Nello specifico, la tecnica con alloggiamento retromuscolare della protesi sarebbe associata ad un alto rischio di inestetismi, quali il "double

bubble” (doppio solco sottomammario) e la cosiddetta “breast animation deformity (BAD)” (ovvero la tendenza della protesi di salire verso l’alto e lateralizzarsi durante la contrazione del muscolo pettorale). E’ proprio questa tipologia di inestetismo che secondo la tesi di parte attrice riscontrata dai consulenti, ha interessato l’attrice: *“Ad oggi la Sig.ra Pt_1 – di anni 34 – presenta, a riposo, mammelle ben proporzionate, caratterizzate da una lieve e fisiologica asimmetria per forma, volume e posizione. Gli esiti cicatriziali – localizzati in sede sottomammaria – appaiono lineari, a decorso trasversale, ben consolidati e riepitelizzati, non aderenti ai piani sottocutanei e lievemente ipocromici. Alla palpazione non si apprezzano evidenti segni di contrattura capsulare. In fase di contrazione dei muscoli pettorali – alle prove dinamiche attive e di controresistenza – si apprezza un depiazzamento delle protesi verso l’alto e lateralmente (maggiore a sinistra) con aumento consensuale dello spazio intermammario (“breast animation deformity”) e formazione di un doppio solco sottomammario (“double bubble”), anch’esso più accentuato a sinistra”* (pag. 21 CTU).

Esaminando le risposte ai quesiti specificamente posti ai consulenti emerge che i CtU hanno ritenuto corretta la diagnosi, in quanto la paziente, affetta da ipotrofia mammaria, è stata sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva, procedura di elezione per la condizione clinica dell’attrice.

Sotto il profilo della scelta specifica del trattamento non hanno, quindi, rilevato elementi di censura: *“circa la generica scelta di eseguire un intervento chirurgico di mastoplastica additiva (unico in grado di risolvere la condizione di ipotrofia mammaria della paziente), né più in particolare di posizionare le protesi mammarie proprio in sede retromuscolare, trattandosi di approccio chirurgico comunemente praticato all’epoca dei fatti per cui è causa ed in linea con le competenze professionali del chirurgo, nonché congruo alle caratteristiche fisiche della Paziente”*. Hanno rimarcato, invece, l’assenza di un adeguato consenso informato in riferimento al tipo di intervento praticato: *“come dianzi esposto, tale trattamento non risulta essere stato preceduto da un’adeguata rappresentazione della procedura chirurgica selezionata, delle sue sequele, nonché delle motivazioni della selezione della tecnica stessa, dei rischi intra e postoperatori ad essa correlati e del risultato estetico conseguibile, anche in riferimento a possibili alternative di trattamento. Le suddette informazioni non risultano annotate nel generico modulo di consenso informato sottoposto alla Periziata né trovano attestazione documentale in precedenti visite mediche effettuate, contrariamente a quanto previsto dalla Controparte_6 sin dal 2015”*.

Dal punto di vista dell’esecuzione del trattamento, i CtU hanno affermato di non aver potuto valutare la correttezza o meno della tecnica adottata dal chirurgo e dei passaggi dell’intervento, a causa dell’assenza della descrizione in cartella dell’atto operatorio in quanto *“il sanitario ometteva di annotare in cartella clinica la descrizione di tutti i passaggi operatori eseguiti sulla Sig.ra Pt_1* ciò

non consente di valutare la condotta del chirurgo in fase intra-operatoria né di esprimersi specificatamente circa l'adeguatezza dell'atto chirurgico espletato, le eventuali difficoltà sopravvenute e/o i rimedi adottati per il loro superamento. Pertanto, gli esiti post-chirurgici oggi obiettivamente, in associazione ad un'assenza di comorbidità preesistenti o sopravvenute (potenzialmente influenzanti il decorso post-operatorio), da un lato non risultano essere stati rappresentati alla Paziente prima dell'esecuzione dell'atto chirurgico e dall'altro non trovano alcun addentellato descrittivo nell'atto operatorio che consenta di meglio comprenderne l'effettiva genesi e quali in concreto siano state le manovre chirurgiche effettivamente svolte. Si tratta in ambedue i casi di condotte censurabili” (v.si pp.22-23 rel ctu).

Hanno rilevato, inoltre, come già accennato, la carenza di consenso informato inerente l'intervento estetico che *“non risulta essere stato opportunamente preceduto dalla compilazione di un valido modulo di consenso informato, bensì dalla firma di un generico documento prestampato, ben distante in termini di specificità e di completezza da quello proposto dalla [...] [...]*

Controparte_6 nel 2015”(pag. 22-23 rel.CTU).

In ordine ai postumi residuati sull'attrice hanno così concluso: *“In definitiva ed alla luce di quanto dianzi espresso, siamo in presenza di esiti post chirurgici di mastoplastica additiva retromuscolare consistenti in Breast Animation Deformity e Double Bubble Deformity (entrambe di grado lieve), configuranti un pregiudizio estetico lievissimo e visualizzabili solo in occasione di certuni movimenti richiedenti il reclutamento specifico dei muscoli pettorali. Questi ultimi rappresentano, invero, la frequente evoluzione della tecnica chirurgica adottata. Non si può, però, negare il grave difetto di documentale informazione e acquisizione del consenso; né si può dimenticare che nel caso in esame non è possibile esprimere alcuna valutazione tecnica sull'operatività chirurgica non risultando la stessa descritta”*. I consulenti, ancora, hanno sottolineato che detta condizione non è suscettibile di peggioramento o miglioramento spontaneo, e che gli esiti sarebbero emendabili soltanto per mezzo di un nuovo intervento chirurgico di revisione al fine di rimuovere le protesi, posizionandole dalla sede retromuscolare a quella retroghiandolare (cfr. pag.24 rel. di CTU).

All'esito dell'indagine espletata dai CTU, è emerso, quindi, che, sebbene i postumi riportati dall'attrice, in interventi di questo tipo, siano spesso conseguenze prevedibili e non prevenibili della procedura, deve ritenersi, tuttavia, censurabile l'attività del sanitario sia per carenza del consenso informato sottoscritto dalla paziente, sia per la mancanza della dovuta annotazione in cartella clinica di tutti i passaggi dell'intervento di mastoplastica additiva del 27.08.2016, nonché delle manovre chirurgiche eseguite.

Sul punto, si osserva, comunque, che l'attrice non ha spiegato alcuna domanda risarcitoria inerente la violazione del consenso informato, essendosi limitata a rilevarlo per la prima volta soltanto nelle note scritte successive all'istruttoria, e pertanto la richiesta sotto tale profilo deve ritenersi tardiva.

Quanto alla valutazione del danno biologico riconosciuto (3%) i consulenti, ai fini della specifica valutazione, hanno preso come riferimento la I Classe di pregiudizio estetico: *nel caso di specie, la valutazione medico-legale non ha potuto prescindere – come è d'uopo – da caratteristiche intrinseche della Periziata, ovvero la giovane età (28 anni al momento dell'intervento chirurgico), il sesso femminile (e l'importanza della sede interessata nella vita relazionale e di coppia) e lo stato anteriore, scevro da ulteriori inestetismi nelle sedi attualmente interessate dagli esiti; il che consente l'attribuzione del punteggio intermedio della fascia (1-5%). Si deve inoltre anche necessariamente tener conto del fatto che l'esito estetico è evidente solo in alcune circostanze dinamiche e non tout court a riposo, durante qualsivoglia movimentazione.*

Non risulta, invece, adeguatamente documentato un danno di natura psichica, ne è stata riconosciuta dai Ctu una incidenza degli esiti chirurgici sulla capacità lavorativa.

Sotto il profilo dell'emendabilità del danno e delle eventuali spese da sostenere, i Ctu, con integrazione alla relazione in atti, hanno chiarito che i postumi potrebbero essere emendati tramite un futuro intervento di revisione, con una spesa di 6.000,00 euro (cfr. integr.Ctu) mentre non hanno ravvisato un danno biologico temporaneo in quanto, al netto del risultato estetico, un intervento felicemente esitato, avrebbe comunque comportato un danno.

In definitiva, all'esito dell'istruttoria espletata, è emerso, che i danni lamentati dall'attrice sono riconducibili alla condotta del chirurgo operatore, che ometteva di annotare in cartella la descrizione dell'intervento, tenuto conto, altresì, della mancata prova da parte del sanitario, che gli esiti della procedura chirurgica siano riconducibili a complicanze prevedibili, ma non prevenibili, e quindi, non dipendenti dalla condotta dell'operatore. Era onere del sanitario convenuto, che non si è costituito in giudizio, fornire la prova della corretta esecuzione dell'intervento o della riconducibilità dei danni a complicanze imprevedibili o se prevedibili, non evitabili, ma tale prova non è stata allegata. Inoltre, a conforto della responsabilità del chirurgo operatore depone l'omessa descrizione dell'intervento chirurgico ove veniva annotato in modo generico *“impianto di protesi mammarie retromuscolari”*, senza far riferimento né al tipo incisioni cutanee e muscolari effettuate, né all'esatta allocazione delle protesi mammarie per poter distinguere se inserite in sede sottomuscolare totale o dual plane. Ed invero, in tema di responsabilità medica, *l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il*

professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione (ex multis, Cass. n.12218/2015; Cass. n. 27561/2017; Cass. n. 26248/2020). Sulla rilevanza sul piano probatorio della difettosa tenuta della cartella clinica da parte della struttura sanitaria, la Cassazione ha ribadito che *«La difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. L'eventuale incompletezza della cartella clinica è, in tale senso, circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno* (Cass. Civ., Sez. 3, 18.02.2021, n. 4424).

Alla luce dei richiami giurisprudenziali sopracitati, deve dichiararsi la responsabilità contrattuale del dott. **CP_1** nei confronti di **Parte_1** per i postumi derivanti dall'intervento di mastoplastica additiva del 27.08.2016, e, di conseguenza, a deve essere condannato, in solido con la **Controparte_2** [...] al risarcimento del danno subito dall'attrice.

Quanto alla liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica, classificando il danno di natura estetica nella fascia della I Classe delle Tabelle SIMLA 2016 (1-5 %), i CTU hanno riscontrato elementi per ritenere integrato un danno biologico permanente nella misura del 3%.

In applicazione delle Tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Roma per l'anno 2023, può pervenirsi alla seguente liquidazione: IP 3% (anni 28 al tempo dell'intervento) = euro 3.103,35.

Alla suddetta somma di euro 3.103,35 occorre aggiungere quanto previsto dal citato art.139 Cda quello riconoscibile all'attore a titolo di sofferenza morale soggettiva, valorizzando le circostanze del caso concreto.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone giustificabile in alcun modo l'incorporazione nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali (cfr Cass. Sez.3 n. 901 del 17/01/2018; Sent. n. 28989 del 11/11/2019; ordinanza n. 7513 del 27/3/18;).

In particolare, la forma di personalizzazione del danno biologico, ha trovato una specifica normativa nell'art. 138 co. 3 del nuovo test. Cod ass, secondo cui "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali, documentati e accertati, l'ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 30%".

La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, pertanto, non costituisce mai un automatismo, ma richiede da parte del giudice, la specifica individuazione di circostanze particolare riferibili al caso concreto che, valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione c.d. tabellare.

Nel giudizio *de quo*, l'attrice non ha provato l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali o particolari riconducibili al tipo di danno subito, ma il mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico, tuttavia, non incide sul riconoscimento del danno morale, come stabilito da giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi"* (Cass. n. 25164 del 2020; in tal senso anche Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019).

Si ritiene, quindi, di poter liquidare l'ulteriore somma di € 800,00 determinata in via meramente equitativa con riferimento ai criteri adottati sul punto dalla Tabella del Tribunale di Roma per il 2023 e tenuto conto di tutte le circostanze del caso in esame quali sopra evidenziate.

Non può essere riconosciuta, invece, la restituzione di quanto l'attrice ha versato come corrispettivo della prestazione sanitaria ricevuta, non avendo la **Pt_1** chiesto la risoluzione del contratto. Ebbene, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione *"nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela"* (Cass., 10/07/2018, n.18086; Cass., n. 6886 del 24/03/2014; n. 29218 del 06/12/2017). Parimenti, non possono essere riconosciute le spese mediche future (€ 6.000,00 come quantificate dai CTU) atteso che, essendo trascorso un cospicuo lasso di tempo dall'evento, non si può ragionevolmente desumere che l'attrice intenda sottoporsi ad intervento di correzione al fine di emendare gli attuali postumi, potendo, altresì, incorrere in nuovi rischi attinenti alla procedura; inoltre, il riconoscimento di tale voce costituirebbe una ingiusta duplicazione risarcitoria del danno già liquidato.

Ne consegue, dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, che il danno da liquidarsi a favore dell'attrice ammonta complessivamente ad € **3.903,35**.

E' necessario, poi, individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, «può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione».

A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (27.08.2016) e quella finale (11.11.2024), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).

Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, si ritiene che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (SS.UU. 5/4/1986 n. 2368).

Quindi, l'importo complessivo di euro 3.903,35 essendo rivalutato alla data odierna in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione e, quindi, al fine di effettuare il calcolo del lucro cessante per il ritardato adempimento della prestazione risarcitoria in presenza di un debito di valore occorre procedere al calcolo della semisomma tra l'importo liquidato alla data della presente sentenza (11.11.2024) e quello devalutato alla data del fatto illecito (27.08.2016) ottenendo l'importo di euro 3.580,78 ($3.903,35 + 3.258,22 : 2$).

Sulla somma di euro 3.580,78 decorrono gli interessi nella misura accordata per i depositi vincolati (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) dalla data del fatto (27.08.2016) a quella dell'odierna pronuncia (11.11.2024), l'importo finale è così pari a € **4.684,18**.

Per la ripartizione delle quote di responsabilità dei convenuti, l'orientamento consolidato sul tema, confortato dalla sentenza n. 28987/19 della Suprema Corte (la quale ha rilevato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria) ha fissato il principio secondo cui il danno da *malpractice* è ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi in cui l'evento pregiudizievole sia scaturito da una condotta del sanitario imprevedibile e improbabile, completamente discordante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di ospedalità. Ne consegue che, per ritenersi superata la prova presuntiva dell'obbligazione solidale, la struttura sanitaria avrebbe dovuto allegare e dimostrare la ricorrenza di tali presupposti.

La mancata prova della condotta dissonante del medico, comporta, come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili, si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e struttura (50%), ne consegue che non può essere accolta la domanda di regresso svolta dalla *Controparte_2* nei confronti del dott. *CP_1* in assenza di una condotta connotata da "*colpa grave*".

Quanto alle spese della Ctu espletata nel presente giudizio, come liquidate in atti, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti, la *Controparte_2* e il dott. *CP_1* [...] in solido tra loro.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il dott. *CP_1* la [...] *CP_2*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra loro, a corrispondere a *Parte_1* la somma di euro 4.684,18 secondo i criteri di cui in motivazione ed interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
- 2) condanna il dott. *CP_1* e la *Controparte_2* in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di *Parte_1*, nella misura di € 2.540,00 per

compenso, di € 300,00 per spese, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Baudino dichiaratosi antistatario;

3) rigetta la domanda di regresso della *Controparte_2* nei confronti del dott.

CP_1

4) pone le spese della CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico del dott. *CP_1*

[...] della *Controparte_2* in solido tra loro;

Così deciso in Roma il 04.11.2024

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giovanna Celona.

IL GIUDICE

Dott.ssa Fabiana Corbo